

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、Aが居住するA所有の家屋に放火し、同家屋を全焼させた上、同家屋に隣接するBが居住するB所有の家屋にも火を燃え移らせて同家屋を全焼させた。この場合、甲には2個の現住建造物等放火罪が成立し、これらは観念的競合となる。
- イ. 甲は、行使の目的で1万円札を偽造し、Aが経営する商店において、事情を知らないAに対し、1万円の商品の購入を申し込み、その代金として偽造の1万円札をAに手渡しして同商品の交付を受けた。この場合、甲には通貨偽造罪、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。
- ウ. 暴力団員甲及び乙は、対立する暴力団員A及びBを襲撃して殺害することを共謀し、路上を連れ立って歩いていたA及びBを待ち構えた上で、甲がAを、乙がBを、それぞれ殺害した。この場合、甲及び乙を共同正犯とする2個の殺人罪が成立し、これらは併合罪となる。
- エ. 甲は、酒に酔った状態で、自動車を無免許で運転した。この場合、甲には酒酔い運転の罪と無免許運転の罪が成立し、これらは観念的競合となる。
- オ. 甲は、恐喝目的でAを監禁し、監禁のための暴行等により畏怖しているAを更に脅迫して現金を喝取した。この場合、監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは牽連犯となる。
1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

No201	罪 数	正答率
共通R5-5	正 解 4	87%

ア 誤っている

大判大 11.12.13 は、被告人が、隣接する他の倉庫にも延焼する可能性があることを認識しながら、他人所有の倉庫に放火し、結果として3棟の倉庫を焼損させたという事案において、単一の放火行為により数個の建造物を焼損したときは、これを包括的に観察して単一の放火罪として処分すべきであるとしている。その理由として、判例は、放火罪においては、静謐なる公共的法益の侵害が主となり、個人の財産的法益の侵害はその従たるものに過ぎないため、放火罪の法益はその主たる関係を標準とすべきであるということを挙げている。よって、本記述においては、甲には包括一罪として1個の現住建造物等放火罪（108条）が成立するのみである。

イ 誤っている

大判明 43.6.30 は、被告人が、偽造銀行券を行使することによって他人を欺罔し、同人から財物を騙取したという事案において、偽造銀行券を行使することによって財物を不正に領得した場合においては、財物領得の行為は、偽造銀行券行使の所為中に包含され、別に犯罪を構成するものではないとしている。すなわち、詐欺罪は偽造銀行券行使罪に吸収されるため、成立しない。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、詐欺罪の成立を認めると、取得後知情行使罪（152条）を特に軽く処罰していることの趣旨が没却されるためであるということを挙げている。よって、本記述においては、甲には通貨偽造罪（148条1項）及び同行使罪（同条2項）が成立し、これらが牽連犯（54条1項後段）となる。

ウ 正しい

最決昭 53.2.16 は、被告人らが数人共同して、複数の被害者に対し暴行・傷害を加えたという事案において、「数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え、一部の者に傷害を負わせた場合には、傷害を受けた者の数だけの傷害罪と暴行を受けるにとどまつた者の数だけの暴力行為等処罰に関する法律1条の罪が成立し、以上は併合罪として処断すべきである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、保護法益の重要性から、被害者ごとに個別に扱う必要があるということを挙げている。そのため、殺人罪（199条）においても同様に、被害者ごとに罪が成立し、併合罪（45条）の関係になると解されている。

エ 正しい ★

最大判昭 49.5.29 は、本記述と類似の事案において、被告人には酒酔い運転の罪と無免許運転の罪が成立し、これらは観念的競合となるとしている。その理由として、判例は、「54条1項前段の規定は、1個の行為が同時に数個の犯罪構成要件に該当して数個の犯罪が競合する場合において、これを処断上の一罪として刑を科する趣旨のものであるところ、右規定にいう1個の行為とは、法的評価をはなれ構成要件の観点から抽象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上1個のものとの評価をうける場合をいうと解すべきである」とした上で、「被告人が本件自動車を運転するに際し、無免許で、かつ、酒に酔った状態であつたことは、いずれも車両運転者の属性にすぎないから、被告人がこのように無免許で、かつ、酒に酔った状態で自動車を運転したことは、右の自然的観察のもとにおける社会的見解上明らかに1個の車両運転行為であつて、……右両罪は刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあると解するのが相当であ」ということを挙げている。

オ 誤っている

最判平 17.4.14 (百選 I 103 事件) は、本記述と類似の事案において、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても、両罪は、犯罪の通常形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず、牽連犯の関係にはないと解するのが相当である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、牽連犯とは、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」(54 条 1 項後段)、すなわち成立した数罪間に「手段・目的」、「原因・結果」の関係(抽象的牽連性)がある場合をいうところ、恐喝は、監禁を手段としなくても遂行可能であり、罪質として監禁を手段とするのが通例といえるほどの強固な密接関連性がない、すなわち抽象的牽連性がないということを挙げている。また、現実の犯行態様において監禁と恐喝との間に手段・目的の関係(具体的牽連性)があったとしても、それだけでは足りないということも挙げている。よって、本記述においては、甲には監禁罪(220 条)と恐喝罪(249 条 1 項)が成立し、これらは併合罪(45 条)となる。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢 4 となる。